

法律解释的公共性

郭春镇*

内容提要 法律解释是一个不断“去私人化”、重构法律文本公共性的过程。法律解释的公共性是一种符号、方法、价值意义上的公共性,以公共偏好、公共理性、公共利益的形态呈现。为了寻求法律“原初”的公共性,解释者应在历时性和共时性的理解中进行视域融合,通过对话与协商统合作者与读者之间、读者与读者之间对文本含义的重叠共识,在往返流转中无限逼近法律文本的原意。为了实现法律“现实”的公共性,解释者应基于人与人之间的交互性关系与互依性关系,将自我塑造为具有关系理性的解释主体;同时,解释者应通过表达与对话机制将个体性解释整合为公共性解读,以此探求文本的“原意”。

关键词 法律解释 公共偏好 公共理性 公共利益 对话与协商

DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2023.01.008

目次

- 一、“去私人化”:法律解释公共性的基础
- 二、偏好、理性与利益:法律解释公共性的内涵
- 三、原意与协商:法律解释公共性的目标
- 四、塑造与对话:法律解释公共性的实现方式
- 五、结语

* 厦门大学法学院教授、党内法规研究中心研究员。本文系2017年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“大数据时代个人信息保护边界与策略研究”(项目批准号:17JZD031)的阶段性成果。在本文写作过程中,王云清、王海洋、黄耀鹏、张慧、熊捷、成立文等同志曾提出意见和建议,特此致谢。

尽管中国法官在具体个案中并无制度意义上解释法律的权限,但如何解释立法者创制的法律文件依然是一个具有普遍意义的方法论问题。在解释标准上,历来存在主观主义与客观主义的对立,立法原意、立法目的、立法文本、动态解释等各种学说并立。^①然而,围绕法律解释的恰当标准或元规则似尚未形成普遍共识,当前法律解释学面临研究瓶颈,甚至有学者抱怨法律解释文献只是一堆可以不去阅读的文献泡沫。^②依我国《立法法》第104条之规定,最高人民法院和最高人民检察院在具体法律适用问题方面的解释,“应当主要针对具体的法律条文,并符合立法的目的、原则和原意”。但该条款实际上是以概括方式规定了法律解释的基本标准,并未回答法律解释的元规则问题。

一些学者选择从方法论的角度破解法律解释的元规则问题,在这一过程中,方法论层面的论述在学界已成显学乃至主流。^③这些论述多聚焦于法律解释的规范性,即法律解释产生的意义所具有的规范效力,却往往把法律解释活动视为解释者围绕法律文本展开的独白,因而无力回应法律解释的合理性追求。如果说法律解释是一种融通了方法论和价值论的技艺,那么基于价值论的解释哲学就不容忽视。实际上,不少学者已经意识到疑难案件的司法决策问题本就表现为对复数的道德价值的选择性适用,在重大、有争议的宪法案件中,“价值论据”(Value Arguments)更是发挥着举足轻重的作用。^④但即便如此,依然有学者认为法律解释没有办法成为裁判伦理学的基础,因为法律解释的研究工作一直关注法律语言学和认识论。^⑤法律解释方法本质上是一个选择与证立的问题,那么是什么决定了解释选择?笔者将对这样一种立场进行辩护:法律解释不是法官运用私人语言解读法律文本,而是要重建对法律文本的公共性理解。这是一种基于立法原意、公共理性及相关需要对法律文本所作的再诠释。沿着这一路标前行,本文探讨法律解释公共性的原理与内涵、适用空间、实现路径,旨在为中国的法治建设提供更充分的理论准备。

一、“去私人化”:法律解释公共性的基础

(一) 法律意义的私人化

法律实施的全部过程都离不开对文本的解释,且这种解释具有不同程度的主观性。从根源来看,所有的法律解释都由个体作出或完成,体现个体对文本的阅读、思考、评价

① 参见雷磊:《再论法律解释的目标:德国主/客观说之争的剖析与整合》,载《环球法律评论》2010年第6期;范进学:《法律原意主义解释方法论》,法律出版社2018年版,第149-222页;Frank H. Easterbrook, *The Absence of Method in Statutory Interpretation*, University of Chicago Law Review, Vol.84:81, p.81-97 (2017).

② See James Landis, *A Note on "Statutory Interpretation"*, Harvard Law Review, Vol.43:886, p.886 (1930).

③ 参见郭春镇、王凌峰:《认知神经科学在法学中的应用研究》,法律出版社2018年版,第2页。

④ 关于“价值论据”在宪法决策中的适用,参见Richard H. Fallon, *A Constructivist Coherence Theory of Constitutional Interpretation*, Harvard Law Review, Vol.100:1189, p.1204-1209 (1987).

⑤ See Anthony R. Reeves, *Judicial Practical Reason: Judges in Morally Imperfect Legal Orders*, Law and Philosophy, Vol.30:319, p.319 (2011).

及在此基础上作出的决定和判断。基于个体的身份和职权,这种决定和判断看似不偏不倚,但由于每个人在作出前述决断之前都会自觉或不自觉地受其“前见”的影响,因而看似客观、中立的决策都带有作为解释者的决策者之主观偏好与价值判断。这样一来,法律解释注定无法绝缘于个体的主观性。由于解释的宽泛性,有学者甚至调侃“解释是一个旅行皮箱一般的词,它是如此具有包容力,以至于几乎所有法院对文本做的事情、用文本去做的事情,无不可视为语义上可允许的乃至正统的意义上的解释”^⑥。

上述观点直接指向如何理解法律解释中的裁量问题。哈特认为,法律文本可能存在“空缺结构”(open texture),也就是法律条文对现实情况可能出现“涵摄不足”的情况,并将其视为司法裁量要解决的难题。^⑦但问题在于,法律解释中的裁量权究竟有多大,法官的运作机制是否有章可循。现实主义法学家甚至认为,法律解释方法不过是法官手中的“魔术棒”“穿衣镜”,或者如果法官是玩家,那么法律解释方法只是他们手中的牌,它们本身并没有发挥引导、约束法律解释的功能,换言之,法律解释其实就是“怎么样都行”(anything goes)。^⑧这种现实主义的立场往往把法律解释问题归结为经验上的感知,特别是以法官为代表的群体在具体个案中对法律意义的处断,而非寻找内在于法律文本当中的意义。正如萨默斯所言,大多数的现实主义者都“持有一种功能主义的意义理论”^⑨。

对于法律解释而言,解释者只有运用共享的语言工具和语言知识,将自己的认知与理解向他者表达,才能形成有效的对话和交流。^⑩现实主义法学指出法律意义在法律实施过程中的生成机制,力促法官结合具体案件的情境寻找妥当的法律意义,但他们往往将这种生成机制归根于法官个人的心理因素。甚至,由于法律现实主义将法律规则的意义视作法官个人的认知活动,由此产生的效果便是,法律解释变成了一种纯粹的语言游戏。然而,只有少数非常极端的现实主义者才会毫无顾忌地鼓吹法官心理因素的决定作用,而且这种观点在现实主义法学内部也不是主流。^⑪一种较为温和的现实主义法学立场主张透过法官个人心理因素,直面其背后的社会性、体制性因素,并鼓励法官尽可能在现有法律语境和社会语境下寻找到正确的答案。譬如,现实主义法学较早的代表人物科亨(Felix S. Cohen)就认为:“真正现实主义的司法决策理论必定认为每项决定不仅仅是个人人格的表达,还是……社会决定的产物。”^⑫基于实效取向的法律解释观念主要出现在现实主义法学理论当中,他们将目光转向法律规范外在的、社会的面向,虽然构建起

⑥ Richard A. Posner, *Legislation and Its Interpretation: A Primer*, Nebraska Law Review, Vol.68:431, p.448 (1989).

⑦ 参见[英]哈特:《法律的概念》,张文显等译,中国大百科全书出版社1996年版,第127页。

⑧ 关于这种观点的代表,可参见 Joseph Singer, *The Player and the Cards: Nihilism and Legal Theory*, Yale Journal of Law, Vol.94:1, p.1-70 (1984).

⑨ Robert Summers, *Instrumentalism and American Legal Theory*, Cornell University Press, 1982, p.53.

⑩ 参见张江等:《阐释的世界视野:“公共阐释论”的对谈》,载《社会科学战线》2018年第6期,第157页。

⑪ 例如,关于现实主义法学曾经流行这样一种叙事方式:法官如何裁判取决于法官早餐吃了些什么。但这种叙事其实是一种断章取义,几乎没有任何一位严肃的法律现实主义者提出过如此夸大的主张。不过,在欧陆现实主义学派那里,我们确实可以看到对法官裁判心理的分析。

⑫ Felix S. Cohen, *Transcendental Nonsense and the Functional Approach*, Columbia Law Review, Vol.35:809, p.843 (1935).

了公共性的雏形,但由于未能留意到内在层面上法律规范本身的意义构造,因而也就未能建立起完整的公共性模型。

(二) 法律解释公共性的寓意

尽管法律解释不可避免地会带有解释者个人的主观偏好,但这并不意味着“法官说法律是什么,法律就是什么”。法律解释不同于一般意义上的法律理解,它代表着体现判断性质的司法权运作,法官也不是在真空当中解释法律文本的。如果把法官刻画成童话故事中的“蛋形人”(Humpty Dumpty)^⑬,可以凭借自己的喜好让词语表达任何一种含义,那么恐怕误解了法官作为解释者的角色定位。从“解释”的本意来说,对意义的揭示离不开共同理解。所谓“解”和“释”,其本意均有“分解、分开,展示其内在”的意思,^⑭体现的是基于还原主义的立场把事物内部展示出来,让受众看清其内部情况,理解其内在含义。那么,解释者向听众传达、揭示事物的含义,就需要运用一套共享的语言工具,而非某种神秘莫测的密码符号。为了让人理解,解释者所用的语言,就不可能是仅自己能理解的私人语言。

法律解释公共性的第一个寓意是,法律解释的一般出发点是法律文本所表达出来的、能够为公众普遍接受的含义,也就是“通常含义优先”。这是因为,据此解释能够最大限度地契合公众对法律条文的适用预期,进而强化法律所具有的“协同”作用。有学者指出,在法律解释的过程中坚守通常含义,除了能够增强法律适用的可预测性之外,还能起到保障程序正义的作用,因为“相比其他解释方法……每个语言言说者更能够获知通常含义”。^⑮需要强调的是,通常含义有时并不等于“显明的含义”,而是代表着一种“合理阅读”后得到的意义。比如,美国一部刑事法规定,“在非法交易毒品期间或与非法交易毒品行为相关”的过程中“使用……枪支”构成刑事违法。在一起案件中,争议的焦点在于被告以枪支交换毒品是否构成这一违法行为。法院多数派利用词典释义认定该行为构成“使用枪支”。然而,斯卡利亚认为,按照通常理解,所谓的“使用枪支”应该是指将枪支作为武器使用。^⑯

法律解释公共性的第二个寓意与立法原意有关。持主观解释论的学者多认为,应以是否符合历史上立法者的主观想法作为法律解释的试金石。在一些疑难案件中,借助立法原意确实有助于澄清法律文本的含义,然而这种解释方法最容易招致的批判是,如果立法者没有通过法律文本表达立法原意,那么这种解释方法无疑是在鼓励立法者运用自己的“私人语言”规制人们的行为。与此相关联,通过立法背景资料推知立法原意的做法同样存在类似的问题。正因如此,在一些国家中,立法背景资料一直以来都被排除在

^⑬ “蛋形人”又名“矮胖子”,是童话故事《爱丽丝梦游仙境》中的人物,主张“我用词的时候,想要它什么意思就什么意思,不折不扣!”。参见[英]刘易斯·卡罗尔:《爱丽丝梦游仙境》,黄健人译,中央编译出版社2010年版,第143页。

^⑭ 参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第5版),商务印书馆2005年版,第700、1250页。

^⑮ See Michael S. Moore, *A Natural Law Theory of Interpretation*, Southern California Law Review, Vol.58:277, p.321 (1985).

^⑯ See Smith v. United States, 508 U.S. 223 (1993).

解释过程之外,或者只有在公众经由合理渠道获取的前提下,方可被法官援引。^{①7}

法律解释公共性的第三个寓意是,法律解释活动必须遵守法律职业共同体的普遍见解,包括法律解释的基本准则。首先,作为一种知识生产活动,在法学界被普遍接受并且能够对法律问题提供较为稳妥的答案的,便是法学通说。尽管法学通说的生产者主要是法学家,但由于其能够对法律实践提供融贯、稳定的指导,因此在法律实务工作者群体中也备受关注。法学通说是在多元竞争的法学理论当中,经过一定标准筛选出来的,这些标准包括但不限于得到法学界的普遍认可、可以从现有法律规范体系中得到支持或者可以基于法律论证获得说服力。“法学通说虽然起源于个体智慧,但却最终形成于学术共同体的‘集体担保’。”^{①8}其次,解释准则虽然“只是帮助法院判断立法含义的经验法则”^{①9},但代表着法院惯例性的司法政策。一些解释准则长期得到公众的认可和接受,比如“法律解释应该从文本出发”“法律解释应该尊重内在体系融贯”“法律解释不可得出荒谬的结果”;还有一些解释准则主要流行于法律职业共同体中,如“格式合同的解释应不利于合同提出方”。虽然法律解释准则属于不具有强制力和最终决定力的规则,但是其不仅影响着法官对法律条文的解释,而且有可能经由司法上的认可反向影响立法机关对法律条文的制定、解释。正是在这个意义上,在一些国家有人戏称法律解释准则是“解释体制”(interpretive regime)^{②0}。

通过以上分析,可以得出一个初步结论:法律解释活动的公共性意味着,法官不能以自己的“私人语言”解释法律文本,而必须以一种指向公共理解的方式形成对法律文本的妥当解释。这就意味着,法律解释工作并非由解释者单独完成,而是在其与作者、其他读者交流和互动的过程中完成的,是协商、调试、修改和完善的过程,解释者本人无力也无法垄断对文本意义的解释。

二、偏好、理性与利益:法律解释公共性的内涵

法律解释的全过程表现为,从法律条文的作者到文本,从文本到读者,从读者的解释到公众对读者解释信息的接收、理解和解读。在此过程中,尊重公共偏好、践行公共理性、实现公共利益是实现法律解释公共性的主要标准。

(一) 公共性中的公共偏好

法律解释中的公共性意味着应尊重公共偏好。偏好是指人们对某些事物具有稳定性的偏爱和喜好,是个人价值排序当中一种独特的心理倾向。^{②1}公共偏好则是一种随着

^{①7} 参见王云清:《立法背景资料在法律解释中的功能与地位——英美的司法实践及其对中国的镜鉴》,载《法学家》2019年第1期,第73-75页。

^{①8} 姜涛:《认真对待法学通说》,载《中外法学》2011年第5期,第938页。

^{①9} Ali v. Fed. Bureau of Prisons, 128 S. Ct. 831 (2008).

^{②0} See William N. Eskridge, *Norms, Empiricism, and Canons in Statutory Interpretation*, The University of Chicago Law Review, Vol.66:671, p.679 (1999).

^{②1} 参见薛洁:《偏好转换的民主过程——群体选择的困境》,吉林大学2006年博士学位论文,第13页。

人类演进而生的追求公平的偏好,^{②②}并在人类社会的发展过程中日趋稳定和理性化。经济学和心理学领域的一些研究成果表明,人们在相互交往的过程中并非只考虑自身福利,也会基于公平和社会偏好顾及他人利益。公共偏好意味着人们在关心自己的利益与福祉的同时,也关心他人的利益与福祉,在理性互动的过程中,在“义”与“利”之间形成一种相对稳健的动态关系,以回避不公平的结果,追求公正的结果。^{②③}公共偏好的形成是复杂博弈的结果,既源自个人神经活动的公平感知,^{②④}也源自个体层面相互博弈过程中形成的妥协,更源自社会层面将个人偏好不断对接、融汇、贯通,并在此基础上产生“化学反应”,形成新的集体偏好,即所谓“公意”^{②⑤}。这种偏好有助于强化身份认同、提升公共福利、推动社会公平。公共偏好程度更高的人们不仅具有更强的群体身份感,能够显著增加群体公共物品自愿供给的数量,还具有更强烈的合作意愿,在外在条件约束下使其所提供的公共物品具有更好的质量。^{②⑥}在此基础上,这种基于公共偏好的群体认同将会影响国民经济管理目标、社会福利水平、社会公平程度。^{②⑦}

在法律实施过程中,对公共偏好的体现与形塑有待进一步强化。公共偏好具有相对稳定性,但受信息不对称、社会环境、个人情绪和认知偏差等因素的影响,也有可能发生变动,使自身难以在法律解释中彰显。首先,关于公案中公共偏好的预判和成立预案机制的研究与实践尚不充分和深入。在中国语境下,公案是指“民众和媒体利用个案内容所涉及的主题元素根据民众需求特点通过议论、诉说、传播和加工而形塑出来的公共事件”^{②⑧}。对于这类引发公众普遍关注与讨论的案件,如果在法律解释后产生多个正确的结果,那么解释应充分考虑公众合法合理的情感,而不应借助对法律的主导性或垄断性话语权,将某些看似专业的判断凌驾于公众情感之上,甚至用似是而非的暧昧话语回应公众的质疑,否则将妨害公众对法律公平的判断和对法律的信任。^{②⑨}其次,对主观程序正义关注不够。程序正义中的主观程序正义对公共偏好和公共解释具有直接的影响。相较于以往从规范角度讨论程序正义,主观程序正义更偏重于真实世界,从经验的角度观察、审视程序正义。其核心是公众对程序的主观性评价,包括程序性因素如何影响公众对公平的感知、程序的参与者或观察者能否感受到程序的公平与正义、程序是否符合公众的

②② See Richard H. Thaler, *Anomalies: The Ultimatum Game*, *Journal of Economic Perspectives*, Vol.2:195, p.195-205 (1988).

②③ 参见马旭东、史岩:《福利经济学:缘起、发展与解构》,载《经济问题》2018年第2期,第14页。

②④ 公平感的形成依赖于人类大脑功能区对公平规范、情境因素、他人行为预期等信息的加工。参见周晓林、胡捷、彭璐:《社会情境影响公平感知及相关行为的神经机制》,载《心理与行为研究》2015年第5期,第595页。

②⑤ 参见[法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆2003年版,第24-25、35-37页。

②⑥ 参见连洪泉等:《信息公开、群体选择和公共品自愿供给》,载《世界经济》2015年第12期,第183-184页。

②⑦ 参见前注②③,马旭东、史岩文,第14-15页。

②⑧ 孙笑侠:《公案的民意、主题与信息对称》,载《中国法学》2010年第3期,第136页。

②⑨ 比如“李昌奎案”的反复。2009年5月16日,云南省巧家县农民李昌奎奸杀同村19岁少女王家飞,并摔死其3岁的弟弟王家红。2010年7月15日,云南省昭通市中级人民法院以强奸罪、故意杀人罪,数罪并罚判处李昌奎死刑,剥夺政治权利终身。二审后云南省高院改判死刑缓期两年执行,引发民意沸腾,后云南省高院在再审中改判李昌奎死刑,剥夺政治权利终身。参见康均心:《还有多少李昌奎被翻案》,载《青少年犯罪问题》2011年第6期,第76-78页。

伦理认知等内容。^⑩ 尽管在研究层面主观程序正义越来越受到关注,^⑪ 在规范层面很多政策和制度安排也体现了主观程序正义,^⑫ 但现实中主观程序正义尚未得到充分重视,违反常理和常情的案件层出不穷,引发了巨大的社会争议并影响到了司法的公信力^⑬。

需要注意的是,尽管法律解释应关注公众的偏好,但这并不等于法律解释问题要依赖公众一时的意见。对法院系统来说,避免公众情绪的干扰一直以来都是司法哲学中历久弥新的问题。原因在于,尽管司法机关在当今社会中越来越发挥着“政策制定者”的角色,但对司法机关的传统预期是,作为一种向后看的机构,理论上其对公众意见的反应相较于立法机关容易“慢半拍”。而且,法律解释答案是否“客观上正确”有时并不依赖于社会共同体中多数派的意见,而是取决于熟悉相关法律制度的专业人士对法律条文的理解。^⑭ 法律解释与公众意见之间错综复杂的关系表明,公众意见更适合作为法律解释合理性的预防机制或检测机制,而非法律解释正确性的唯一判断基准。

(二) 公共性中的公共理性

法律解释中的公共性意味着应践行公共理性,将公共偏好整合成“公意”也需要践行公共理性。公共理性是人们基于公共意识和公共理由对某种正义原则或公共政策进行讨论,并接受讨论形成的“重叠共识”。^⑮ 它的形成有赖于公共精神以及由此而来的合作态度,并为公民和公权力的运行提供公共理由与正当性支撑。在这个意义上,它是一种主体间的理性,是关系理性、交往理性,而非独白式的理性,^⑯ 是对个人理性与工具理性的超越。通过人与人之间的关系及由此而来的对话和交往来实现正义,是比通过某个或某些实质性的结果或某个实体价值的实现更具有正当性、更接近正义的方式。

解释是读者对作者制作的文本进行理解、阐释的活动与过程。作者创作文本时会体现其意志和意图,文本对作者具有某种相对确定的“意义”(meaning),但不同的读者对文本有不同的理解,因此文本对读者具有某种深层结构的“意味”(significance)。^⑰ 让“意义”和“意味”进行对接、整合乃至融合的,是基于这种主体间关系理性的解释。公共理性不仅从“交互性关系”理解人的存在,强调在尊重他人意志和自由前提下主体的意志和自由,还从“互依性关系”理解人的存在,强调自我与他者互相依赖、互为目的。^⑱

^⑩ 参见苏新建:《主观程序正义对司法的意义》,载《政法论坛》2014年第4期,第128页。

^⑪ 参见冯健鹏:《主观程序正义研究及其启示》,载《环球法律评论》2018年第6期;苏新建:《程序正义对司法信任的影响——基于主观程序正义的实证研究》,载《环球法律评论》2014年第5期。

^⑫ 参见郭春镇:《感知的程序正义——主观程序正义及其建构》,载《法制与社会发展》2017年第2期,第106页。

^⑬ 如“许霆案”,相关评述参见李红海:《认真对待事实与将常理引入司法——减少争议判决之司法技术研究》,载《法商研究》2018年第5期;马荣春:《论刑法的常识、常情、常理化》,载《清华法学》2010年第1期。

^⑭ 关于法律的客观性问题,存在最低客观性、中度客观性和强客观性等多种不同的立场。认为法律问题不依赖于个别法律人的看法,而是依赖于社会共同体中多数派的看法,属于最低客观性立场。但这个立场受到格林沃特等人的批判。See Brian Leiter, *Objectivity and the Problems of Jurisprudence*, Texas Law Review, Vol.72:187, p.187-209 (1993).

^⑮ 参见[美]约翰·罗尔斯:《作为公平的正义——正义新论》,姚大志译,上海三联书店2002年版,第55页。

^⑯ 参见吴英姿:《司法的公共理性:超越政治理性与技艺理性》,载《中国法学》2013年第3期,第65页。

^⑰ 参见[美]斯坦利·费什:《读者反应批评:理论与实践》,文楚安译,中国社会科学出版社1998年版,第157-169页。

^⑱ 参见贺来:《“关系理性”与真实的“共同体”》,载《中国社会科学》2015年第6期,第30页。

这种理性使得不同主体之间能够有效互动,在互动中实现“意义”和“意味”的融合。它既发生在作者和读者之间,也发生在不同读者之间。它来自作者的初始语言活动和来自读者的理解和认知活动进行了对接,将不同读者的理解及“意味”进行了整合与贯通,进而实现了融合,在“来龙”和“去脉”之间形成了有机统一的整体。

在法律解释中实现公共理性,仍存在着较大的提升空间。在解释法律文本的过程中,司法裁判确定性的追求成为法律人的某种“情结”,这种“情结”具有深厚的心理基础和学术理由。^{③⑨}但法律解释有时限要求和成本约束,因此应超越对完美确定性的追求,在进行哲学审思的同时面对现实与实践。法律解释应当避免只考虑法治的形式性,注重法律源自统治者的意志并有国家暴力作为保障这一面向,而忽略法律适用和法律解释的实质法治取向。因此,在法律解释中实现公共理性,应在“亚确定性”^{④①}的基础上通过对话与协商探索更具可接受性的结果。这种公共理性注重调和不同主体之间的关系,既尊重有权解释者的权力行使行为,也尊重公共情感和公共偏好,基于不同主体之间的理性共识进行法律解释,促成作为解释者的“读者”和作为解释受众的“读者”之间的交流、对话和互动。这种对话和交流,不仅发生在法庭上,还发生在法庭外。舆论和“众意”就是对话的一种方式,这种对话的结果可以反映在制度性行为中,如在“公案”的司法裁判中反映经由理性疏导的公众意见,又如在申请再审的过程中将公众意见纳入考量范围。

在这个意义上,法律文本、法律文本的作者、法律文本的多重读者之间进行了直接或间接的对话与交流。这体现为在法律实施的过程中,法律规范提供了一个框架,^{④②}框架内有足够的空间容纳复数正确答案。法律实施者在把法律事实纳入框架并衡量后,会提供答案或结论。框架的大小取决于框架语言的射程及多个射程交叉而成的空间大小。当法律事实遭遇这一框架时,会产生一束可能性的答案或结论。这些答案或结论既是确定的也是不确定的,确定的是在框架之内,不确定的是哪一个是“最正确”的,是契合公众认知与公共理性的。公共理性使得读者可以不断趋近作者的原意,从一束答案或结论中搜索翻检,将答案从亚确定性向确定性移动并无限接近“最正确”的。这意味着,对某个具体问题的求解,公共理性可能无法指向某个具体的答案,它的关系、对话和交往特性使其具有“求同存异”的禀赋。通过不同主体自觉践行公共理性,可以取得主体间的共识,并在此基础上寻找更具可接受性的“最佳”答案。

(三) 公共性中的公共利益

践行公共理性的目标是实现公共利益,即共同善。公共利益以物化形式和非物化形

^{③⑨} 参见田源:《行为法律经济学视野中的“法律确定性命题”——以规则和标准的分类为线索》,载《法制与社会发展》2018年第2期,第45页。

^{④①} 郭春镇:《务实的法治观应立足于裁判的亚确定性》,载《法学研究》2012年第6期,第24页。

^{④②} See Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, translated by Max Knight, University of California Press, 1967, p.350-351. 凯尔森认为解释活动的主要任务是限制正当、合理的解释结果的范围。和凯尔森的观点相似,美国学者惠廷顿也倾向于认为,“解释”与“建构”(construction)是两种不同的活动,解释可以限制文本的可能解释,但不能得出具体的结论,后者属于“建构”的范围。See Keith E. Whittington, *Constructing a New American Constitution*, Constitutional Commentary, Vol.27:119, p.120-121 (2010).

式呈现。物化形式体现为国家或社会所提供的个人可直接享用的物质性利益,包括教育、社会保障等。非物化形式是关乎人们精神生活健康和幸福的道德福利,^④包括生活于特定社会文化背景之中并由此追求和享受到的各种目标、情感、历史性记忆等,是人们思想和行动的意义来源,也是共同体得以存续的价值基础和内在驱动力。

在法学、政治学和经济学中,公共利益是较为模糊的概念,存在不同理解。由于公共利益的主体范围、判断标准均难以勘定,因此“用固定的语言去界定公共利益往往徒劳无益”^⑤。一种偏向于怀疑主义的立场还可能认为,公共利益只不过是“精心设计的一种‘神话’或意识形态,用以遮掩有价值利益的配置过程”^⑥。对怀疑主义者而言,公共利益根本不存在或难以界定,主张在法律解释中体现公共利益更是无稽之谈。然而,必须强调的是,从规范上看,有不少法律条文明确规定了公共利益,有时即便在法律条文中没有提及公共利益,公共利益也未必不存在。而且,公共利益并非只能存在于涉及公权力的纠纷之中,还可以存在于纯属私人主体之间的纠纷中。^⑦就此而言,立足于现有的规范体系、整全性的价值立场和中国法治建设的实践需求来理解公共利益,仍不失为一种有效进路。

在法律规则的适用方面,对公共利益的体现、保护和保障仍有诸多不足,以至于可能产生具有误导性的判决。公案判决具有指向性作用,会对人们在类似情况下作出何种决定、在“向未来看”时采取何种决策产生引导与激励作用。比如,在著名的“彭宇案”中,法官依据“经验法则”推定彭宇是撞倒老太太的人,^⑧但无论是在经验法则的运用还是案件说理论证层面上,都极易导致公众在需要对他人施以援手的情境下选择明哲保身^⑨。总之,实现法律解释的公共性应追求公共利益,而实现公共利益需要践行公共理性,审视、省思公共偏好,并对接近与体现“公意”的内容予以接纳。

三、原意与协商:法律解释公共性的目标

法律解释的公共性具有历时性和共时性,它的实现需要在纵向的历时性与横向的共时性理解中进行“视域融合”。如果我们承认法律解释的公共性,那么法律解释理论中

④ 参见钱宁:《“共同善”与分配正义论——社群主义的社会福利思想及其对社会政策研究的启示》,载《学海》2006年第6期,第37页。

⑤ 胡鸿高:《论公共利益的法律界定——从要素解释的路径》,载《中国法学》2008年第4期,第56页。

⑥ Charles A. Reich, *The Law of the Planned Society*, *The Yale Law Journal*, Vol.75:1227, p.1235-1236 (1966), 转引自[美]理查德·B.斯图尔特:《美国行政法的重构》,沈岷译,商务印书馆2011年版,第23页。

⑦ 如在“张学英诉蒋伦芳遗赠纠纷案”中,泸州市中级人民法院认为黄永彬基于其与张学英非法同居关系而订立的遗嘱虽是其真实意思表示,但内容和目的违反了法律规定,损害了社会公德或社会公共利益,应属无效法律行为。参见四川省泸州市中级人民法院(2001)泸民一终621号民事判决书。

⑧ 参见“徐寿兰诉彭宇人身损害赔偿纠纷案”,江苏省南京市鼓楼区人民法院(2007)鼓民一初212号民事判决书。

⑨ 如在后续小悦悦案件中,广东佛山女童小悦悦相继被两车碾轧,18名路人经过但都视而不见,直到一名拾荒阿姨上前施以援手,该事件引发了人们对社会冷漠的谴责与反思。参见尹于世:《从“小悦悦案”更应反省内心的冷漠》,载《新华每日电讯》2012年9月7日,第3版。

的作者中心主义立场、文本中心主义立场或读者中心主义立场,都将不再是理想的选择。质言之,法律解释活动毋宁说是在法律文本这一基础上,统合历史上立法者之原意和当下读者对法律文本之协商,根据社会时代发展需要动态地形成基本共识的过程。因此,欲实现法律解释的公共性,需要妥善处理好原意与协商之间的关系。

(一) 探求法律文本“原意”中的公共性

尽管原意论作为一种解释理论常常被批评为“考古学”,但原意论尊重法律原意、以“求真”的严谨态度求解法律意义的做法依然值得尊重。^{④⑧}然而,法律解释中的“求真”与其说是真理符合论意义上的,毋宁说是融贯论意义上的“最佳解释”。这往往会使解释者跳出“厚”的繁冗文本,以一种较为宏观的、“薄”的态度解读,前提是这种“薄”不能无视存在于法律条文和法律体系中的价值。^{④⑨}这种价值就是法律文本产生之初所蕴含的公共偏好、公共理性与公共利益。在对诸多冲突的价值进行衡量时,“真”是最根本的价值,它立足于文本进行解释,但这并不意味着将目光局限于文本,更不意味着是“文本之外无救赎”^{⑤⑩}式的“文本拜物教”。这是因为,文本是一个客观存在,是在历史和文化语境中对某些意义与价值的展现,不归属于任何个体。如果不考虑文本自身的含义、在历史长河中对文本的历时性理解、解释者的理解、解释指向对象的理解等因素,则意味着歪曲乃至篡改文本。鉴于立法原意代表着相对稳定的共识理解,探寻并尊重立法原意本身就体现了公共性。

有学者认为,坚持历史上立法者的原意是一种相对保守的做法。^{⑤⑪}这种批判虽然有一定的道理,但不足以否定原意解释立场的重要性。一方面,从维持法律制度的相对稳定性和公众的合理预期而言,法律本身就应当是向后看而非向前看的。^{⑤⑫}另一方面,原意解释有时并不能直接地等同于历史上立法者的主观想法,因为构成原意的内容可能包括文本提出者的原意、文本拟订者的原意、文本批准者的原意,以及在这些主体不存在的情况下通过对立法背景资料的整理与推理、通过亲历者的回忆所呈现的原意等,关于此类原意的理论与实践已充分展示了问题的复杂性。^{⑤⑬}立法原意有时可以表现为立法者对特定问题的具体解决方案的构思,有时可以表现为立法者通过法律规范想表达的语义内容,有时可以表现为立法者试图实现的某种抽象目的。因此,对规范文本“原意”的追求是无止境的,且存在多个不同原意相竞争的可能。

^{④⑧} See Larry Kramer, *Two (More) Problems with Originalism*, Harvard Journal Law & Public Policy, Vol.31:907, p.907-916 (2008).

^{④⑨} 图什奈特曾就宪法文本的解释方法谈及“薄”的做法,其中,“厚”的是法律文本,“薄”的是法律价值、法律原理。参见[美]图什奈特:《让宪法远离法院》,杨智杰译,法律出版社2009年版,第66页。

^{⑤⑩} 这是格雷马斯的名言,转引自[意]马西莫·里奥尼:《高保真、低保真、无保真与无线保真阐释——与张江教授关于文本意图问题的讨论》,权达译,载《社会科学战线》2017年第6期,第153页。

^{⑤⑪} 参见魏治勋:《原意主义解释方法的难题及其司法实用进路》,载《学习与探索》2012年第9期,第67-72页。

^{⑤⑫} 参见[美]波斯纳:《法律理论的前沿》,武欣、凌斌译,中国政法大学出版社2003年版,第149页。

^{⑤⑬} 学界已有诸多探讨原旨主义的文献,如张翔:《美国宪法解释理论中的原旨主义》,载《山东社会科学》2005年第7期;侯学宾:《美国宪法解释中的不同民主观——原旨主义和能动主义之比较》,载《当代法学》2010年第1期。

我们不妨以富勒 (Lon L. Fuller) 曾经构想过的“任何车辆不得驶入公园”为例加以检视。^{⑤4} 对于这个条文的立法原意,可能有多种理解:(1)立法者制定这一法律规范的意图是维护公园环境整洁、空气清新,以太阳能为动力的汽车可以驶入公园;(2)立法者制定这一法律规范的意图是维护公园作为居民自由活动的场所,一切可能带来交通隐患的车辆都不得驶入公园,包括以太阳能为动力的汽车;(3)立法者制定这一法律规范仅仅是想从语义角度传达一条绝对禁令,立法者把“车辆”视为种类物,并未明确其外延;(4)立法者在构思这一法律规范时,明确地想到了特定品牌、型号的车辆不得驶入公园。那么,上述何种解释更符合立法原意呢?很显然,上述解释并不存在绝对意义上的正误之分,而是一种相对意义上的优劣之分。

当法律规范出现合乎法律文本规定的多种解释可能时,衡量和决定解释优劣的标准往往就在于何种解释更符合公共性。质言之,只有当立法原意解释和公共性耦合时,才可以判断立法原意解释是否适当。以最高院指导案例66号为例。我国《婚姻法》第47条规定:“离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。”那么,一方在离婚诉讼期间或离婚诉讼前,存在上述不诚实行为的,可否适用该条款?第一种观点认为,依照字义解释,应将“离婚时”严格解释为“离婚诉讼期间”;第二种观点认为,“离婚时”应从“分居时起算”;第三种观点认为,应对“离婚时”进行扩张解释,只要在离婚时发现一方故意隐瞒其曾经的擅自处分行为,均推定行为人存在不法处置财产行为,可以少分或不分财产。对此,法官们认为,前两种理解有悖于《婚姻法》第47条的立法目的,可能会纵容非法处置夫妻共同财产行为,因此采纳了第三种解释。^{⑤5} 该规定的立法原意在于保护夫妻对共同财产的所有权,避免一方的合法权益遭受非法侵害,法官们对“离婚时”的扩张解释契合维护相对弱势一方合法权益的立法原意。由此可见,经由原意解释方法实现法律解释的公共性,方能使法律解释尽可能地靠近公共偏好和公共理性。

探寻法律的原意与“初心”,须从公共性着手。公共性中蕴含的公共利益、公共理性和公共偏好内在地要求探索法律文本的原意。一般而言,法治国家制定的法律,是公意在规范中的体现,其确认和保护的也是经过公共理性淬炼之后所形成的公共利益。即便是某些保护私人利益的规范,虽然指向的是私人利益,但由于涉及不特定多数人甚至每一个人,因此其总体目标仍然是公共利益。在这个意义上,凡是经过法定程序、充分征求和吸纳了社会意见所形成的法律法规,都直接或间接地指向或体现了公众的利益。而公共偏好在解释的过程中被吸纳和萃取,成为公共利益的有机组成部分。

众所周知,法律解释是法律人安身立命的技艺。这意味着它既是一种技术,可以像

^{⑤4} See Lon L. Fuller, *Positivism and Fidelity to Law — A Reply to Professor Hart*, Harvard Law Review, Vol.71:630, p.662-663 (1958).

^{⑤5} 参见最高人民法院案例指导工作办公室:《〈雷某某诉宋某某离婚纠纷案〉的理解与参照——婚姻法第四十七条规定的“离婚时”含离婚诉讼期间与离婚诉讼前》,载《人民司法·案例》2018年第2期,第32-33页。

科学技术一样通过刻苦的训练、反复的实践获取,同时也是一种艺术,需要在事实与规范之间往返流转时作出恰切的价值判断和价值衡量。这一艺术判断能力当然也可以训练,但其过程并不像逻辑推演那样直白、直接以及可以通过逻辑技术进行检验。它更多地体现为在诸多价值中作出判断,在价值质与量的大小与多少之间进行审视和斟酌,有时甚至会有豁然开朗乃至心有灵犀的微妙感受。随着法律规范数量的爆发式增长,法学研究与法律应用的分类越发精细化、专业化,法学理论、法律规范更加复杂难懂,知识、书本和法条的厚度也日渐增加。法律人有时会迷失其中,忽略乃至忘记法治方向、法律原理和价值。解决问题的思路是超越文本而立足于其内在价值作出预判,并基于此寻找相应的规范,对决定进行合法律性论证。在法律解释中实现公共性,在萃取公共偏好、形成公共理性并在此基础上确认和保护根本意义上的公共利益时,可能要面对各种复杂的流程、环节和信息轰炸。在这个过程中,坚守法的基本价值与初心,需要在技术层面上把规范条文变“薄”,在价值层面上牢固把握“薄”的原则。

(二) 通过“协商”实现法律文本中的公共性

原意解释方法受到的一种质疑是,其虽然可以指明法律文本应该如何被解释,却不能决定法律文本应该如何被适用。^{⑤6} 法律解释的公共性要求充分尊重文本的原意。这意味着当一个读者或解释者面对文本时,需要有在历史长河中与其他读者、解释者或者作者协商的意识和行为,以探求法律文本的“规范意义”,否则难以作出符合原意的解释。

法律文本中必然存在着原意。这种原意不一定是某个特定文本写作者或拟订者的原意和意图,因为诸多写作者和拟订者的想法和目的不一定相同,甚至可能截然相反。但是,不论其间经过何种辩论和斗争,文本能够最终定稿并产生法律效力,仍体现了参与者们的共识性意图,即意图的最大公约数。探求“原意”意味着寻求更有机的解释,它不仅希望探知所有参与法律文本制定的人们的共识性意图,还希望将文本适用于规范实践和行为实践中,整合多方理解并进行融合。这既包括在规范实践中把续写者们的意图和原作者们的意图进行对接乃至汇聚,也包括在行为实践中把运用法律的读者(法官、检察官和律师等法律职业者)和其他读者(当事人和其他参与、关注纠纷解决的人)的意图进行整合并使之产生“化学反应”,这些都需要在协商中达成。

其一,探求整全性的原意需要协商。裁判语境下的“整全性”原本是指一种司法裁判过程中规则适用的解释理念和原则,其主旨是把法律置于一个整体性、体系性的结构框架内进行理解,将包括政治道德在内的诸多价值准则融贯在一起,以求获得一个“尽可能最好”的答案。^{⑤7} 实现法律解释公共性中的公共偏好、公共理性和公共利益,要求将不同群体的前述价值准则进行整合与融通,使其具有整全性。首先,整全性的实现需要在解释时进行“视域融合”,^{⑤8} 而这需要协商。无论法律职业者还是普通社会成员,个人

^{⑤6} See Keith E. Whittington, *The New Originalism*, *Georgetown Journal of Law & Public Policy*, Vol.2:599, p.611 (2004).

^{⑤7} 参见[美]罗纳德·德沃金:《法律帝国》,许杨勇译,上海三联书店2016年版,第83、133页。

^{⑤8} 参见[德]汉斯-格奥尔格·加达默尔:《真理与方法:哲学诠释学的基本特征》(上卷),洪汉鼎译,上海译文出版社2004年版,第391-393页。

观察问题的角度总是受限于自然条件、物质条件和认知能力。因此,需要秉持开放的心态,从历史与现实、不同主体的不同立场、不同种类的规范所蕴含的不同价值等多重视域来观察和审视问题,在此基础上进行整合并作出判断。这要求主体能够对来自不同视域的观点进行协商,以促成视域融合乃至整全性的实现。其次,整全性需要在解释时有良善的“前见”,而这也需要协商。前见是“被设定了”的“先入之见”,^{⑤⑨}是理解的前提和基础。在对文本进行理解和解释时,“前见”是不可避免的,否则就无法理解文本,更不用说解释。但是,前见有“真”有“假”。假的前见会造成误解,真的前见则是洞见,有助于理解和解释文本。前见需要通过整全性原则的检视,^{⑥⑩}检视的过程就是不断对话、协商和批判的过程。在这个过程中,反思和扬弃假的前见,形成真的前见,并将这种前见不断更新和升级,进而用更新后的前见理解和解释文本。由此,对法律文本的解释处于不断建构和持续性开放之中。最后,整全性需要议论,而这也是协商的重要方式。重要法律的立、改、废,疑难案件和公案的审判,总是容易引发法律职业者和社会公众的关注和议论。关注的内容和重点或许有分歧,对法律实施的程序、结果及其所涉的各种主客观利益或许有不同的理解和辩论,但这种协商有助于眼光不断地在文本的作者、续写者、解释者和读者等群体之间往返流转,并把道德、政策、法律等诸多规范中的价值融入其中,逐渐趋近共识与“最正确”的答案。通过协商,在不确定性中获得最具可接受性和权威性的确定性。当然,议论和协商不一定发生在不同主体之间,同一主体也可以在视域融合的过程中不断修正自己的前见,自己与自己协商并达成和解与共识。

以法律解释中的想象性重构方法为例。想象性重构方法意味着在法律文本难以精准涵摄法律问题时,不是将文本视为立法者的独白,而是由法官从立法者的立场与视角考量如何给出答案,给出一个相对合理的裁判结果。^{⑥⑪}想象性重构方法带有明显的法律续造性质,且无法脱离法官的价值性评判,但是这并非裁判者的擅断,而是其与立法者进行“协商”、在探寻过去的理解与当下的社会共识是否保持一致的基础上寻找到的答案。对此,美国法官伊斯特布鲁克曾坦言:“最好的法官会发现,与消逝的立法者的想象性对话,和当前法官对善的认知有诸多类似之处。”^{⑥⑫}由此可见,想象性重构方法追问历史上立法者对当下的可能判断,实际上是一种追求、实现当前社会偏好的漏洞填补技术,是一种“协商”的技术和艺术。总之,实现整全性需要协商,协商既可以促成视域融合、形塑良善前见,也可以促成不同群体之间乃至同一主体形成历时性共识。

其二,探求融贯的原意需要协商。融贯性意味着动态流畅地保持内在一致性,它是主体基于对客观世界的感知和内省而产生的信念之间的融贯,既包括同一主体不同信念

^{⑤⑨} 参见张江:《前见是不是立场》,载《学术月刊》2016年第11期,第118-119页;[德]马丁·海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,三联书店2006年版,第176页。

^{⑥⑩} 参见金玲:《德沃金建构性法律解释学中的“效果历史”》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2011年第4期,第37页。

^{⑥⑪} 参见王云清:《制定法解释中的想象性重构》,载《法律科学》2017年第3期,第50-52页。

^{⑥⑫} Frank H. Easterbrook, *Legal Interpretation and the Power of the Judiciary*, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol.7:87, p.92 (1984).

之间的融贯,也包括不同主体的信念之间的融贯。^{⑥3} 实现法律解释的公共性需要在叙述和规范层面保持动态流畅的融贯。这是因为,公共偏好、公共理性和公共利益有客观现实的一面,需要在法律实践中将其真实地还原,这是一种叙述性融贯。同时,公共偏好、公共理性和公共利益也有规范的一面,法律中的规范性命题需要相互印证,保持内在一致性和统一性,这是一种规范性融贯,是超越个案的法律体系的融贯。^{⑥4} 整体性融贯则将事实、规范体系进行整合,要求得到的材料既能够融合各种规范的一般性原则,又能保持价值上的一致性,就像写作和续写小说的诸多作者们所做的那样。^{⑥5}

就同一主体而言,融贯性需要主体在解释时进行自我认知和信念的交流,这是一种协商。主体的认知能力、判断能力和决策能力都随着其自身成长的历程而不断变化,一个成熟的主体是在对自己幼年、青年时的一些想法和观点不断修正、扬弃的过程中走向理性的。就不同主体而言,也需要在协商中交流观点,修正自己的态度,以使其更具正当性。不同主体在协商过程中会形成重叠共识,且这一过程可以是共时性的,也可以是历时性的。比如,相对论在扬弃牛顿力学的基础上让自己更具有理论正确性,在这个意义上,爱因斯坦在和牛顿协商,牛顿生活在爱因斯坦之中。

融贯性需要在解释时实现从局部融贯到整全性融贯的跨越,这也需要协商。融贯是循序渐进的,先通过对某些事实的合理裁剪和语言的有效重构,形成事实与信念的融贯。比如,我国现行宪法先后五次修改,每次修改都是在原有文本的基础上形成的一种新的“嵌入”关系。从嵌入的过程和结果来看,它们体现了制宪者和修宪者意志和意图的延续与统一,形成一个蕴含新旧文本价值双重属性的新事物。通过试错性纠偏和反思性均衡,在特定群体内、特定规范体系内形成局部融贯,最后在群体之间、规范体系之间形成整全性融贯。在这种状态下,诸多规范体系及其价值如同多种金属元素,通过协商的火焰锻炼成为新的、具有更好物理化学属性的合金,实现了整全性融贯。比如,一部在互联网上征求意见的法律草案,会收集不同群体基于不同价值立场和偏好的观点,这必然涉及不同价值观、不同社会规范理念的交锋,促成不同群体之间的交流。交流即协商,诸多规范体系和价值在协商中进行交涉和互通,形成最大公约数,由此构成法律的基础性共识。

四、塑造与对话：法律解释公共性的实现方式

为探索文本的原意,并在不同的作者与读者之间形成共识,以实现法律解释的公共性,需要塑造具有关系理性的解释主体,需要解释主体在表达与接收信息过程中有效协商,并在沟通和对话中求得文本的原意。

^{⑥3} 参见[英]苏珊·哈克:《证据与探究:走向认识论的重构》,陈波等译,中国人民大学出版社2004年版,第2-3、74-78页。

^{⑥4} 麦考密克将融贯分为叙述性融贯和规范性融贯。参见侯学勇:《麦考密克论融贯》,载《政法论丛》2008年第2期,第90-93页。

^{⑥5} 参见前注^{⑥7},罗纳德·德沃金书,第178-218页。

（一）解释主体关系理性的塑造

对法律文本进行解释的主体应具有关系理性。解释主体是文本的“读者”之一,需要对文本的诸多作者和其他读者的理解进行融合,形成具有整全性和融贯性的解释,这一目标的实现需要关系理性。关系理性蕴含“关系”和“理性”两层含义:前者是从“超越实体化、原子化的个体的社会关系”以及人与人的“交互性关系”和“互依性关系”的角度对自己定位;后者是从“理性形态的转换和变革”的视角对人的存在的“实在性”重新定位,是对抽象共同体的客观理性与抽象个体的主观理性的双重超越。^{⑥⑥}

关系理性是时代发展与进步的产物。在古代社会,个体不是作为一个独立的行动主体和权利义务主体出现,更多地是作为群体的成员出现,其道德法律权利义务设置也相应地由其在群体中的身份所确定。在现代社会,理性更多地被视为个人“主体”的本质属性,个人的意志和利益不再被认为应该无条件地服从抽象的共同体。相应地,这一时期个体的道德法律权利义务不再由其身份而是由其个人意志决定,个体可以根据自由意志与他者通过契约设定自己的权利义务。这一转变过程,在法律层面体现为“从身份到契约”^{⑥⑦}的演进过程。契约法律化的过程也是社会原子化的过程,这种原子化社会从个人出发,将他人视作实现自身权利与利益的工具。立足于契约的法律仅在形式上将社会整合为一个整体,^{⑥⑧}但在运作过程中容易引发社会联结机制缺失、公共性变弱、人与人之间缺乏有效互动、社会陷入无序和混乱等问题^{⑥⑨}。关系理性旨在弥合以上缝隙,主张从人与人的“交互性关系”和“互依性关系”理解人的存在,强调人与人之间的相互承认和相互依赖,拒斥一个人对另一个人的外在支配与控制,拒斥将别人作为实现自身欲望和利益的工具和手段。^{⑦⑩}相应地,其对道德法律权利义务的设定与解释既要尊重人的主体性和能动性,又要注重基于不同的社会情境、角色、关系动态地调整。

解释主体塑造关系理性,需要将自身置于“真实的共同体”之中。在“真实的共同体”中,每个人处在自己的联合中并通过这种联合获得自由。^{⑦⑪}这要求解释主体塑造积极的主体意识,把自己“摆进去”,加强与其他主体的协商、对话,形成良性的合作与联合关系,并基于这种关系进行解释。此时,解释主体既置身于该“真实的共同体”中,又能够让各方参与、对话,通过人与人的联合来获得各自的自由,最终也实现法律解释的公共性。当然,这还需要解释主体积极能动地回应并维护好这种联合关系。如果说传统社会强调共同体利益至上进而使得个体被融化在群体中,现代社会则注重个人的主体性并且个人意志与利益常游离于共同体之外,进而使得个体“原子化”并造成“共同感”的

^{⑥⑥} 参见前注^{③⑧},贺来文,第30-31页。

^{⑥⑦} [英]梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1996年版,第96-97页。

^{⑥⑧} 参见张康之:《论契约的建立与扬弃》,载《中国人民大学学报》2006年第5期,第94-95页。

^{⑥⑨} 参见田毅鹏、吕方:《社会原子化:理论谱系及其问题表达》,载《天津社会科学》2010年第5期,第73页。

^{⑦⑩} 参见前注^{③⑧},贺来文,第30页。

^{⑦⑪} 参见《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社2012年版,第199页。

消退,那么马克思所设想的使得个人既充分独立又与他人一体的“真实的共同体”,^{⑦②}就成为理想的共同体。在这个共同体中,每个人都能意识到自己的活动与他人相关联的可能性,并且根据共同的期望和目标来提高彼此的个性。

一个公正的共同体以自由个性的全面发展为条件,而且自由个性的价值与共同体的价值彼此一致。共同体中的成员相互承认,主体和“客体”之间的统一性在承认中得以重建。主体不再是异化的外在的他者,而是作为共同的类主体的一个方面而相互联系。^{⑦③}在这个共同体中,人不再被理解为手段,而被理解为目的,不再因自私自利而出现一部分人对另一部分人的战争,人在生产实践活动中成为“为他人”的存在,因而“关系理性”才得以成为马克思所说的“共同体”的伦理前提。当然,关系理性虽然强调人与人之间的关系,有时在外观上类似于传统社会的身份话语,但它把人当作目的,而非身份话语下的手段,因此迥异于客观理性社会。

解释主体塑造关系理性,需要在协商中整合与凝聚“公意”,并尊重与执行公意。公意是真正意义上的人民意志,它经由公共理性使诸多“众意”发生“化学反应”后形成并体现公共利益,由此成为实现公共利益的先导。由于不同主体具有不同的认知水平和信息获取能力,加上某些道德运气的因素,总会产生一些个性化的偏好,这些偏好和他人的偏好对接整合之后,有可能形成体现某些群体利益和意志的偏好,这些偏好更像是“众意”。即便这种意志是通过投票产生的多数意见,也并不能代表公众真正偏好的、以公共性服务为旨归的公意。尽管人们的偏好有不同程度的个性化,其情感和意见有主观色彩,但终归有一些共通之处或人类的共同属性。如“孺子将入于井”时人“皆有怵惕惻隐之心”以及人皆有“羞恶之心、辞让之心和是非之心”。^{⑦④}如果说偏好体现的是一种口味,那么作为人类的一员,个体在很多方面都有相似的“道德味觉”^{⑦⑤}。因此孟子所说的“故理义之悦我心,犹刍豢之悦我口”^{⑦⑥}才显得振聋发聩,令人无滞碍地产生心理认同。真正的公意和公共偏好,是将各种意见和偏好进行融会贯通,并由此形成融汇各种偏好和意见的最大公约数。此时,公共偏好是公共情感的主观表达,关系理性是一种基于人与人之间的关系而形成的可以客观展示的理性样态。

解释主体在探寻文本原意时,需要遵守关系理性。原意所依存的文本固然有其语义射程,以及基于此的通常理解,但又有一定程度和范围的不确定性,这也是原意是否存在、探求谁的原意等理论纷争产生的原因。^{⑦⑦}基于人是目的而不是手段以及人与人的交

^{⑦②} 参见前注^{③⑧},贺来文,第42页。

^{⑦③} 参见[美]古尔德:《马克思的社会本体论:马克思社会实在理论中的个性和共同体》,王虎学译,北京师范大学出版社2009年版,第2-20页。

^{⑦④} 参见《孟子·公孙丑上》。

^{⑦⑤} [美]乔纳森·海特:《正义之心:为什么人们总是坚持“我对你错”》,舒明月、胡晓旭译,浙江人民出版社2014年版,第135页。

^{⑦⑥} 《孟子·告子上》。

^{⑦⑦} See Mitchell N. Berman, *Originalism is Bunk*, New York University Law Review, Vol.84:1, p.5-7 (2009).

互性和互依性关系来探索原意,或许会发现别有洞天。文本的平义解释(plain meaning)为我们理解文本提供了一个大致方向,在人与人的共时性和历时性关系中,我们可以无限趋近文本的真正“原意”。法律解释不是被动地探寻文本原意的过程,而是一个创造的建构性过程,需要从沟通对话的角度来理解法律文本,否则可能走向文本原意的对立面。^⑧探寻文本原意的过程,就是带着建构真实共同体的期许与同侪协商、与先贤对话的过程。这个过程会加深对文本的理解,凝聚对文本背后的价值立场的认同。每一次对原意的探索,都需要“听”和“说”,在协商和对话中“听到”和“被听到”,在一次次听和说中,逐渐把“我”和“他者”凝聚成“我们”,把文本中最基本的价值观凝聚成“我们”的价值共识。在这个意义上,法律解释的公共性决定了对话与协商的需求和方式。追求关系理性,就是在协商中探索真正的原意,在原意的探寻过程中形成关系理性。

(二) 解释主体有效对话的实现

作为“读者”,解释主体需要跟作者和其他读者对话,如果说和作者的对话需要跨越时间的界限,是历时性的、虚拟而间接的对话,那么和同时代其他读者的对话,则是共时性的、现实而直接的对话。对话与沟通是对文本的原意进行学理探究,在探索文本来龙去脉的同时对文本的“真实意思”进行确认的整合机制,这种机制的有效运转,有赖于通过你来我往的交流表达各自观点、情感并在此基础上协商,进而不断形成重叠共识、达成合意。由此,充分的表达成为有效对话的前提,有效对话为表达提供了保护与保障。

表达是借助言论、出版、电影、电视和互联网等媒介,将人们的思想、情感与观点以多种形式展示出来的一种行为。^⑨表达的目的是信息传递和交流,内容则涉及世界的各个方面。表达可以分为两个阶段。第一阶段是一方将自己的观点、想法、情感等向外界表露、展示和传播;第二阶段则是向外传递的信息到达接收者的接收系统中。接收意味着信息接收系统以主动或被动的方式收到表达者传递的信息。尽管“接收”不同于“接受”,收到某个信息并不意味着接受或承认它,更不意味着根据该信息采取行动,但接收这一行为构成协商的开始,信息接收方可以通过表达向信息发出方反馈信息,在表达和接收的循环中,信息往返流动,从而形成了协商。在“表达—接收—表达”的循环过程中,表达无疑是信息交流和有效协商的开端。因此,需要通过制度性安排对表达进行确认、保护和保障,表达权由此应运而生,并成为有效对话的动力机制。

表达是一种单向度的信息传递过程,使真正的思想市场得以汇聚各类文本的私人化解读,而对话则可以使表达转换成公共性的双向或多向互动行为,并在对话中求得被解释文本的原意,是一种使法律解释个体化部分发展成公共性的整合机制。

首先,对话使得求真成为可能。对话是交涉、交流和沟通的方式,可以在双向或多向互动过程中反复对文本的内在进行展示,求得文本的真实意义。不可否认,每个主体在对文本进行解释时,都会或多或少地受自己前见的影响。不同人基于不同的立场、观点、

^⑧ 参见张保生:《法律推理中的法律理由和正当理由》,载《法学研究》2006年第6期,第87页。

^⑨ 参见杜承铭:《论表达自由》,载《中国法学》2001年第3期,第57页。

实践、偏好乃至利益,往往会有意无意地对文本作出不同程度的强制解释。对话则可以在不同程度上抵消那些影响客观判断和理解的偏见。当众多主体对文本进行解释时,可以通过在循环往复交流的过程中不断消除强制解释的因素,逐渐向体现公共偏好、公共理性和公共利益的解释靠近。这样,对话通过整合单向度解释中的不同观点来凝聚共识,通过“公共性”整合不同的解释,使得不同解释中的真相或真理性的一面得以展示。

其次,对话使得“求薄”成为可能。“薄”意味着能够穿越规范文本中的文字可能带来的迷雾,探求文本背后的价值内核。法律自身的特点决定了其表达要严谨精准。法科学生非常重要的训练内容之一,就是用法言法语把问题进行重新表述。法律职业群体通过解释权力的垄断实现对涉及法律规则运行的各类事务的话语垄断。这种权力基于形态上的两个特点,远离法律职业群体之外的人们。一是这种话语变成业内人士才能准确理解的“行话”;二是承载这些行话的文本越来越冗长繁复,一般人无法删繁就简,获得其中最根本和重要的信息。与此同时,随着社会的发展和人们生活复杂性的增强,越来越多的事项和事务被纳入法治化轨道。相应地,法律也越来越繁杂,以至于从事某一领域的律师对其他领域的法律事务都难以理解,更不用说没有受过法学训练的普通人了。而对话使这种被法律语言的繁复所遮蔽的法的核心价值能够被公众了解、理解和掌握,尤其是在引发公众普遍关注的公案中。比如,人们可能并不了解“李昌奎案”^{⑧〇}“百香果女孩案”^{⑧1}中的法律细节和某些法律文本与理论的意义,不知道自首、死刑、酌定减刑的确切含义,但能够基于对死刑立即执行和死刑缓期执行的区别对审判结果产生质疑,且基于这种质疑产生的理性对话有助于人们发现和理解法律中的核心价值立场,摆脱一些不恰当情结和理念的影响。在实践中,最高人民法院已经关注到这种对话,并通过调卷审查的形式来回应作者与读者之间、不同读者之间的对话。^{⑧2}

最后,对话能够促进反思,使文本的边界被逐渐勾勒出来。反思不仅仅是“以思想的本身为内容”^{⑧3},还是一种“后思”和反向性、反复性的思考,是对“初思”“前思”的改造和升华。无论是反思性认可还是反思性拒斥,都表明反思的批判性和超越性必须立足于文本但超越文本,在“真”和“薄”的基础上确定边界。所有对文本的解释都有边界约束,是框架范围内的有限多元选项集。规范文本构成了框架及其边界,即语义的通常和正常“射程”。在这个文义射程或者边界范围之内,所有的解释都能够从文本中获

⑧〇 参见李芹:《李昌奎故意杀人强奸案再审宣判》,载《人民法院报》2011年8月23日,第3版。

⑧1 2018年10月4日中午,陈礼言10岁的女儿杨某燕,帮家里采摘百香果到收购点售卖,被犯罪嫌疑人杨光毅强奸杀害。2019年7月12日,钦州市中院一审以强奸罪判处杨光毅死刑,剥夺政治权利终身,责令退赔32元给杨某燕母亲陈礼言。杨光毅不服,提出上诉。2020年3月25日,广西高院二审对其改判死刑缓期两年执行,剥夺政治权利终身,限制减刑。该案经媒体报道后,引发舆论高度关注。参见欧阳晨雨:《“百香果女孩”遇害案:让正义以看得见的方式实现》,载《中国青年报》2020年5月15日,第2版。

⑧2 在百香果女孩一案改判死缓后,网友对此看法不一,有人认为“判决有失正义”,也有人认为“舆论影响司法”。2020年5月20日,最高人民法院经研究决定,对广西壮族自治区高级人民法院二审终审的杨光毅强奸一案调卷审查。参见司楠:《“百香果女孩被害案”死刑复核裁定书亮点解读》,载《人民法院报》2021年4月1日,第6版。

⑧3 [德]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,商务印书馆1980年版,第39页。

得正当性支持。也就是说,对文本的解释具有限定的确定性,凡是在这个范围之内的解释,都符合文本的基本主旨,不能称为错误的解释。但是,这种解释也有不确定的一面,因为我们无法确定在边界内的正确的复数解释中,哪一个才是“最正确”的答案。在某些情况下,在边界范围内寻找到一个解释即可完成解释任务,但在很多情况下,还需要更进一步,使文本能够为公众所理解并在此基础上与公众进行有效对话,在对话中不断缩小具有亚确定性的选项范围,直至寻找到的最具有可接受性也“最正确”的答案。^{⑧4} 对话的批判性和超越性,使得解释具有建构性和动态性。建构性意味着问题的答案不是无中生有,而是在现有的文本材料、对话内容中用好前见、消除偏见、确定基本价值立场,探寻文本原意,发现语义射程和边界,在复数正确解释中基于场景动态地寻找最恰当的一种。动态性则意味着寻找文本材料内容是一个动态过程,可以随着场景的变化和时空的位移发现不同的最适合当时当地的素材,并根据现实需求将其置于不同的位置。只有在这种动态的建构过程中,文本方可获得“最正确”的解释。

五、结 语

从理解的角度来看,任何解释都具有公共性,否则无法被受众理解。法律解释的公共性不仅体现在理解的意义上,还体现在对公共偏好的尊重、公共理性的遵循和公共利益的追求上。这种公共性,既体现出文本作者与解释者之间在法律价值与意义上的视域融合,也体现了对社会善治和法律良善的追寻。^{⑧5}

法律解释的公共性,有赖于探求法律文本的“原意”与“初心”,通过“对话”与“协商”来实现。这种解释不是每个读者自我理解意义上的“碎片化”解释,^{⑧6}而是在融合读者与文本作者多元理解的基础上对文本原意的探索。尽管自文本诞生之日起作者就不能垄断对文本的解释,但作者本身作为一种话语实践的符号,成为理解文本理论和观念的一个权威来源。^{⑧7} 不同读者之间、读者与作者之间对法律文本的解读可能大相径庭,这就需要读者与他者之间进行跨时空的协商和对话,不断形成重叠共识,进而无限逼近“最正确”的答案。

对话与协商是实现法律解释公共性的方式,而这必须建立在信息表达与接收是有效且贯通的基础之上。这既要求表达者具备关系理性,也要求有促成其有效表达的制度安排。前者意味着表达的主体应基于“交互性关系”和“互依性关系”理解自身的存在,

^{⑧4} 比如,在“李昌奎案”中,云南省高院的死缓判决是边界内的选项之一,因此难以被称为错误判决。但这个判决显然不是“最正确”的答案,所以才引发社会各界的广泛关注与批评,最终改判为死刑立即执行。参见赵秉志、彭新林:《我国死刑适用若干重大现实问题研讨——以李昌奎案及其争议为主要视角》,载《当代法学》2012年第3期,第34页。

^{⑧5} 参见解永照:《论法律解释的目标》,载《山东社会科学》2017年第3期,第185页。

^{⑧6} 参见宋小海:《论法律文本的结构解释——以富勒“程序自然法”学说为视角》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2016年第6期,第80页。

^{⑧7} 参见苏力:《解释的难题:对几种法律文本解释方法的追问》,载《中国社会科学》1997年第4期,第22页。

尊重他人的尊严与价值,将他人视为成就自我的目的,拒绝将他人作为实现自我利益的工具或手段。后者意味着表达权能够为这种信息表达与接收的有效贯通提供动力机制,在对话与协商的基础上确保不同观点的碰撞与交流。在践行关系理性的过程中,通过共同体内部成员之间的对话与协商求得最大范围的重叠共识,对法律文本的原意进行动态、澄明的解释,使得多个与多重的个体性解释经整合成为公共性的法律解释。

Abstract: Legal interpretation is a process that continuously reduces ‘private languages’ to reconstruct the publicity of legal texts. Publicity of legal interpretation means the publicity of signs, methods, and values that appear in forms of public preference, public reason and public interests. On one hand, in order to seek ‘primitive’ publicity, the interpreters need to get the fusion of horizons both diachronically and synchronically, and integrate the overlapping consensuses regarding legal texts between authors and readers as well as among the readers through dialogues and negotiations, by which to approach the original meaning of laws. On the other hand, in order to realize ‘realistic’ publicity, the interpreters should not only cultivate themselves into ones with relational rationality based on the interaction and interdependence between people, but also integrate private interpretations into public interpretations through mechanisms of free expression and dialogues, so as to grasp the original meaning of laws.

(责任编辑: 强梅梅)